2026 年度　立命館大学法科大学院
入学試験（中期日程）　講評

憲法	1 ページ
民法	4 ページ
商法	8 ページ
刑法	10 ページ
小論文	17 ページ

憲法

問題Ⅰで検討すべき問題は、A 県警による①Xに対する令状に基づく捜索押収（ノートパソコンと携帯電話）と②Xのノートパソコンのデータ（「事件処理簿一覧表」、「刑事企画課だより」）消去が、X の取材の自由を侵害するかどうかである。

本問を報道の自由の問題として論じる答案が多く見られたが、取材物の押収、消去がされている以上、本問は取材の自由に対する制約と考えるべきである。取材の自由の保障は、「将来の取材活動を著しく困難にする措置を受けない権利」を含むことを指摘した上で、本問では「取材物を強制的に収奪されない自由」が問題になることを論じなければならない。なお、適正手続（憲法 35 条、31 条）違反について論じる答案も散見されたが、本件は令状に基づく捜査であるため、適正手続違反は本質的争点とはならない。

取材の自由の憲法上の保障について、参照すべき判例は博多駅テレビフィルム提出命令事件（最大決 1969 年 11 月 26 日刑集 23 巻 11 号 1490 頁）である。ただし、Xはニュースサイトを運営するウェブメディアであるため、判例のいう「報道機関」に含まれるのかを論じなくてはならない。この判例の射程について触れていない答案が大半であった。

①と②の合憲性を判断する枠組みとしては、日本テレビ事件（最二決 1989 年 1 月 30 日刑集 43 巻 1 号 19 頁）や TBS 事件（最二決 1990 年 7 月 9 日刑集 44 巻 5 号 421 頁）を参照すべきである。判例は、適正迅速な捜査のために取材の自由がある程度の制約を受けることはやむをえないとした上で、取材資料の押収の可否は比較衡量によって判断するとしている。答案上は、判例の比較衡量の判断枠組みの問題点を批判して、目的手段図式の厳格な違憲審査基準を設定することもありうる。多くの答案が何らかの判断枠組みを設定することができていたが、判例を十分に踏まえたものは少なかった。

事案の具体的な検討では、Xに対する①捜索押収と②データ消去のそれぞれについて検討することが求められる。①について、捜査側の事情としては、捜査の対象がA県警の警察官の守秘義務違反という重大な事案であること、内部資料提供者を特定するにはニュースサイトを直接捜査する必要性があったことは指摘できよう。しかし、A県警に批判的な報道をしたウェブメディアに対するA県警自らの強制捜査を認めてしまうと、将来の同様の批判的報道に極めて重大な萎縮的効果をもたらすことになる。また、本件の内部資料提供は、「公益通報」あるいは「内部通報」にあたる可能性が高いところ、このような内部からの情報提供にも強い萎縮的効果が働くことも避けられない。とくに、内部での自浄作用が期待できない組織的な隠ぺい質がある場合には、より深刻な問題となる。

②のデータ消去については、正当化する余地はおよそ考えられない。内部資料であることはデータ消去を正当化する理由とはならないし、消去しなければ直ちに重大な危険が発生することも想定できず（刑訴法 121 条 2 項参照）、データ消去は捜査目的（証拠保全）に一切役立たないからである。

答案の中には、①と②のいずれか一方のみを論じるにとどまったものや、両者を区別せずに混同したものが少なくなかった。しかし、押収の概念に廃棄（消去）は含まれない（刑訴法 110 条の

2、99 条 2 項参照）以上、①と②を峻別して、それぞれの合憲性を検討することが不可欠である。①と②を峻別して、上記の問題意識をもって事案分析を展開できていた答案は、高く評価した。

問題 II の主要な論点は、要するに「国民主権の原理」という場合の「国民」の定義である。出題の文章の末尾に、「特別永住者などの定住外国人も審査権を有する旨を定めることは、国民主権の原理に抵触することになるかならないかについて論じなさい」と記してあるのは、このことを示している。この場合の「国民」が抽象的な観念として「主権」の名義を意味するのにとどまるというのではなく、むしろ具体的な集団として「主権」の主体を意味するという文脈においては、自己統治に関与するのに相応しい生活実態の人々のうち、日本国籍の人々のみが構成員であるべきなのか、たとえば「特別永住者などの定住外国人」が構成員に含まれることにしてもよいのか、ということが基本原理に関わる憲法問題になる。
出題の文章には、最高裁判所裁判官国民審査法（昭和 22 年法律第 136 号）第 4 条の「審査権」と公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 9 条第 1 項の「選挙権」を挙げてあるが、最大判 2022（令和 4）年 5 月 25 日（民集 76 巻 4 号 711 頁）は、「審査権が国民主権の原理に基づき憲法に明記された主権者の権能の一内容である点において選挙権と同様の性質を有することに加え、憲法が衆議院議員総選挙の際に国民審査を行うこととしていることにも照らせば、憲法は、選挙権と同様に、国民に対して審査権を行使する機会を平等に保障しているものと解するのが相当である」と判示している。およそ「国民主権の原理」という場合の「国民」である限りは、という裁き方だが、日本国外に居住する日本国籍の人々の事件だから、この場合の「国民」が日本国籍の人々に限られるのか、という点が裁かれているわけではない。
ヒッグス・アラン事件の最 2 小判 1993（平成 5）年 2 月 26 日（判時 1452 号 37 頁）は、公職選挙法第 9 条第 1 項の「日本国民」という要件を合憲と判定するにあたり、ロナルド・アラン・マクリーン事件の最大判 1978（昭和 53）年 10 月 4 日（民集 32 巻 7 号 1223 頁）の「趣旨に徴して明らか」と判示している。マクリーン事件判決には、「思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である」と判示されており、これらの最高裁判例において「日本国民」が日本国籍の人々を指しているのは明らかである。もっとも、論文式試験の優秀な答案などとは異なり、そのこと自体の理由が説明されているわけではない。
法科大学院の法学既修者コースの新入生には、最高裁判例の要旨を応用したり批判したりする能力の伸長も期待される。だから、本問の出題は、入学後の伸長が合理的に見込まれる能力を架空の事例問題の解答として遺憾なく発揮してくれることを要求している。
このような出題趣旨を誤解している答案が少なくなく、たとえば「国民主権の原理」について正当性と権力性の両契機を説明しないで、もっぱら国語辞典に登載されているような「国民」の語義に依拠しているとしか見受けられない答案も散見された。また、広義の参政権に分類される「審査権」と「選挙権」を単純に混同していると見受けられる答案もあった。これらとは対照的に、

出題趣旨を誤解することなく、たとえばマクリーン事件判決の要所を適切に活用していたり、あるいは国民審査と総選挙の同時実施という憲法上の制度設計の含意にまで論及していたりする答案は、そのように検討していること自体も評価することができた。

民 法

[Ⅰ]

(1)　抵当権の追及効(追及力)

抵当不動産甲について抵当権の登記がされていると、甲が第三者に譲渡され所有権移転登記がされても抵当権を実行できる効力のことである。この趣旨を書けている答案はかなり少なかったが、書けていても登記されていること(対抗要件を備えていること)が書き込めていないものがあった。誤った解答で多かったのは、抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲(370 条の付加一体物)の説明をしたり、物上代位の説明をするものであった。抵当目的物からの分離物に効力が及ぶか(山林から伐採された樹木など)の例を挙げた解答には、内容に応じて評価した。

(2)　中間最高価格の賠償責任

損害賠償の対象である目的物の価額が一度上昇後に下落した場合、一番高い額を基準に損害賠償を求められるかという問題で、判例は利益取得の確実性と予見義務を要件とする。

問題の定義と 416 条 2 項を不法行為に類推適用した富喜丸事件判決の判断基準である利益取得の確実性と予見義務（当時は予見可能性）をしっかり書いて欲しいが、字数の制限があるので、基準は 416 条 2 項＋利益取得の確実性とか富喜丸事件判決などの簡略な説明でも一定の評価をした。定義について「最高価格と現在時価の中間」とか中間利息控除と間違えている答案が散見され、これらはまったく評価しなかった。評価額が上下する場合であることを示したものは部分的に評価した。基準について、416 条 2 項や予見可能性あるいは予見義務だけを書いた答案は少し足りない。

[Ⅱ]

〔1〕

(問 1)

A は B に支払った 100 万円を取り戻したい。B、C、D に対して支払いを求めることはできるかが問われており、損害賠償請求を考える必要はないと限定されている。

まず、A は乙の売買について、詐欺取消権(96 条 1 項)を行使することが必要である。そうすると、B には 100 万円の原状回復請求が可能である(121 条の 2 第 1 項)。なお、給付利得の場合の返還の範囲は現存利益ではなく、受け取った物をそのまま返還して原状回復すべきである。

なお詐欺取消しではなく、錯誤取消し（95 条）や契約内容不適合による解除（562 条、564 条、542 条 1 項 1 号）を論じている答案も散見されたが、要件の充足について正確に論じていればそれなりに評価した。

ここまではかなりできていたが、C、D への請求については誤りが多く見られた。B に 100 万円を請求できるが、支払われる可能性は低いから、A としては C、D に請求をしたいところである。しかし、C、D と A との間には契約関係はなく、B との乙の売買契約を取り消しても A は原状回復請求できるわけではない。また、金銭は占有あるところに所有権有りであり、A は C、D

に所有権に基づく返還請求をすることはできない。したがって、請求根拠として考えられるのは不当利得返還請求である。ここでもさらに問題がある。C は B から協力の謝礼(?)として 20 万円の支払を受けたのであり、D は貸付金の弁済として支払を受けた。D については、B から 80 万円の支払を受ける法律上の原因があることが明らかである。金銭の信用力を維持するには、金銭の出所によって受け取った金銭の返還が認められるべきではない。他方、A は B に 100 万円をだまし取られており、A の保護を考えたいところもある。特に、C は 20 万円の出所について悪意である。これは、いわゆる騙取金による支払と支払先に対する不当利得返還請求の問題である。最判昭和 49・9・26 民集 28 巻 6 号 1243 頁によれば、不当利得返還請求権が成立する要件は、利得・損失の存在、両者の間に「社会通念上の因果関係が存在し」、法律上の原因がないつまり受益者が騙取金であることについて「悪意または重過失であること」である。これに従うと、C は騙取金であることについて悪意であるから、A は 20 万円の返還請求ができ、D にも、D が悪意または重過失であれば 80 万円返還請求可能である。ただ、D は消費者金融なのでその可能性は低いと考えられる。

不当利得返還請求の問題として論じたものでも、判例によらず、703 条をそのまま適用したものが多かったが、内容に応じて評価した。誤った解答では、C、D が 96 条 3 項の第三者として保護されるとするものがあった。とても基本的な事項なので、96 条 3 項の第三者について再確認しておいてほしい。C について、第三者の詐欺を論じたものもあったが、契約当事者の B 自らが詐欺を働いておりあえて第三者の詐欺をいう意味もなく、また第三者の詐欺の効果としては B が悪意であれば A は B との契約を取り消せるだけであり(96 条 2 項)、ここから C に対する返還請求が導かれるものでもない。

(問 2)

A は B に売った甲を取り戻したい。まず、A は甲の売買について詐欺取消権(96 条 1 項)を行使することが必要である。意外にこれが明記できていないものが多かった。A、B 間には甲と乙の二つの売買契約が存在することを、解答の途中で忘れてはならない。

しかし、甲は B から E に転売されており、A が所有権を回復したとして所有権に基づく返還請求を E にすれば、E は 96 条 3 項の第三者として保護されると主張することになろう。問 2 の E は、取消前の第三者であり、B の詐欺について善意無過失であれば保護されることになる。しかし、A による甲の売買の取消しという点が抜けてしまったせいか、96 条 3 項による E の保護を論じずに、甲が動産であることから、E の即時取得(192 条)を検討する答案も少なくなかった。即時取得の検討はもちろん誤りではないが、詐欺取消しをしたはずなのに、96 条 3 項に全く触れることなく、即時取得のみが論じられているのは妙な感じをぬぐえなかった。

〔2〕

(問 1)

BA 間において、訪問着を仕立てて B 宅に送付する旨の請負契約（632 条）が締結された。B は契約締結に際して A に対し、結婚式の 1 週間前である 2025 年 6 月 30 日に自宅に届くように送って欲しいと伝えていたのに、訪問着の仕上がりが大幅に遅れて同年 7 月 10 日午後に発送さ

れたため B は友人の結婚式に訪問着を着て出席できなかった。そこで、B は A に対し、着物のレンタルにかかった費用と訪問着を着て友人の結婚式に出席できなかったこと（精神的損害）について責任を負わせたい。B は A に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求（415 条 1 項）をすることが考えられる。

※なお、訪問着を友人の結婚式に着て友人の結婚式に出席できなかったことは契約の目的を達成することができなかったと評価できることから、B は 542 条 1 項 4 号に基づく無催告解除をしつつ、債務不履行に基づく損害賠償請求（545 条 4 項・415 条 1 項）をするという法律構成でも良い。

B の請求に対して、A の側から（1）履行補助者である C の仕立て作業の遅延による責任であり A の責任ではない、（2）仮に（1）が認められないとしても、着物のレンタルにかかった費用と訪問着を着て友人の結婚式に出席できなかった精神的損害については損害賠償の範囲に入らないという反論が考えられる。

415 条 1 項が適用されるための要件は、①債務の存在、②「債務の本旨にしたがった履行をしない」または「履行不能」に該当すること、③債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由がないこと、すなわち債務者の免責事由がないこと、④損害の発生、⑤債務不履行と損害との間に因果関係があることである。

以上を本問の事案にあてはめると、①について、A は本件契約締結により、B に 2025 年 6 月 30 日までに訪問着を仕立てて B 宅に送付する債務を負っていた。

②について、A が 2025 年 6 月 30 日までに訪問着を完成させ B 宅に送付できなかったことは「債務の本旨にしたがった履行をしないとき」に該当する。

③について、本件のように、債務者が債務の履行のために第三者すなわち履行補助者を使用した場合において、債務不履行が履行補助者の行為により生じたとき、これが免責事由にあたるか否かは契約の趣旨および取引上の社会通念より判断される。A は本件契約締結後、C に対して余裕をもって訪問着を仕立て上げ、配達日を 2025 年 6 月 30 日に限定して B の自宅に送付するよう指示しているが、その後は、作業工程とその進捗状況、完成した訪問着の送付について一切確認をしていないため、A 自身に債務不履行について責められるべき事情があるといえる。また、呉服店が着物の仕立てを受注後、職人に作業を任せることは取引上の社会通念に照らして通常であることに鑑みても、債務者である A がリスクを負担すべきではないと評価できるような事情はない。したがって A の反論（1）は失当であり、A に免責事由は存在しない。

④について、財産損害とは、債務不履行がなければ債権者が有していたであろう財産状態と、債務不履行があったために債権者が現に有する財産状態との差額を金銭で表したものをいう（差額説）。差額説に照らすと、B は A の債務不履行がなければ訪問着の仕立て代・送料込みで 50 万円を支払うだけで済んだのに、債務不履行によりさらに 1 万円を着物のレンタル料として支払わざるを得なくなった。また、訪問着を着て友人の結婚式に参列できなかったという精神的損害を被った。したがって損害は発生している。

⑤について、指定日に訪問着が A 宅に届かなかったために、A は上記支出を余儀なくされ精神的損害が発生したのであるから、債務不履行と損害との間に因果関係が認められる。また、これ

らの損害は、契約が履行されなかったために生じた通常損害であるから（416 条 1 項）、損害賠償の範囲としてすべて認められる。したがってAの反論（2）は失当である。

以上のことから、B の A に対する請求は認められる。

答案では、415 条 1 項の要件定立とあてはめが不明瞭なものが散見された。とりわけ、債務者の免責事由の認定が甘い傾向にあった。A と C とが使用者・被用者の関係にあると認定し、B が A に対して 715 条の使用者責任を負う旨を 415 条 1 項の適否を論じるプロセスに混在させているものも見られたが、基本的な論理展開が出来ていない。また、415 条 2 項の填補賠償請求の可否を論じるものも散見されたが、（問 1 ）において B が求めているのは填補賠償請求ではなく遅延賠償請求であるので誤りである。精神的損害は、債務不履行に基づく損害賠償の範囲に含まれず、不法行為に基づく請求においてのみ認められるという論述も見られたが、誤りである。

（問 2 ）

① B は A に対して、完成した（送付された）訪問着の「品質」に関して不適合があることを 1 年以内に通知し（637 条 1 項）、追完請求として訪問着の仕立て直しを請求することが考えられる（559 条・562 条 1 項）。この不適合が注文者 B の責めに帰すべき事由によって生じたという事情はうかがえず（562 条 2 項）、B が供した材料の性質又は B の与えた指図によって生じたとも認定できない（636 条）。また、B 宅に送付された訪問着の修復は不可能であるが、同じ反物が存在しており、それを仕立てた代替物を引き渡すことができるのであるから、B の A に対する追完請求は認められる。

答案では、概ね良く書けていたが、品質に関する不適合について 1 年以内に請負人に通知する旨の指摘が抜けている答案が散見された。

② B 宅に送付された訪問着は修復不可能であり、同じ反物も存在しないのであるから、追完は不能すなわち履行不能（412 条の 2）である。そこで、B は A に対して、1 年以内に訪問着の「品質」に関して不適合があることを通知した上で（637 条 1 項）、559 条・564 条・542 条 1 項 1 号ないし 5 号に基づく無催告解除をし、これに基づく原状回復請求（545 条 1 項）として 50 万円の返還を求めることになろう。

答案では、追完不能・履行不能であることの指摘が全くなされていないものが見られた。また、追完不能を前提として、B が A に代金減額請求（563 条 2 項 1 号）をする旨論じられている答案が比較的多く見られたが、修復が不可能である訪問着をこのまま手元に置いていても何ら使いようがなく、転売して利益を得ることもできないことから不適切である。

商 法

Ⅰ

取締役の競業避止義務や、従業員の引抜きに関する忠実義務に関する理解を試す設問である。甲社としてＢ取締役にとれる法的措置としては、監査役ＤによるＢの違法行為の差止請求（措置１）と、同じくＤ（甲社を代表）によるＢに対する損害賠償請求（措置２）が考えられる。また、別途、取締役会決議によるＢの非常勤取締役への降格（取締役会の構成から可能である）（措置３）や、株主構成にもよるが、株主総会決議によるＢの取締役からの解任（措置４）に触れてもよい。

便宜上、措置２から検討する。措置２については、Ｂの協業避止義務違反による甲社への損害賠償請求と、Ｂの従業員の引抜きという忠実義務違反による甲社への損害賠償請求の二つが考えられる。

競業避止義務から検討すると、Ｂが取締役の地位にある甲社と、Ｂが代表取締役の地位にあり全ての取引につき会社を代表しうる乙社は、中価格帯の和装小物のインターネット販売で、すなわち取扱商品や販売地域で競業関係にある。したがって、Ｂは、甲社の取締役として、第三者（乙社）のために会社の事業の部類に属する取引を行っており（会社法３５６条１項１号）、また、甲社の取締役会の承認を受けていないことからその競業取引により乙社（第三者）が得た利益の額が甲社の損害額と推定される（会社法４２３条２項）。競業取引や、取締役会承認を欠く任務懈怠と、甲社への損害発生は因果関係があり、その請求は認められる。

次に従業員の引抜きにつき検討すると、引抜行為は取引ではないため競業取引に関する規律は問題とならず、一般的な取締役の忠実義務（会社法３５５条）違反という任務懈怠による損害賠償請求となる。本件勧奨の態様は強引とは言えないが、在任中の取締役による引抜行為であり、Ｂの忠実義務違反による任務懈怠は明らかである。また、退職した２名は、甲社への業績貢献は乏しいものの、後任者のリクルート費用や、教育費用は、引抜行為と因果関係を有する甲社の損害として認識しうる。その範囲で、請求は認容されよう。

措置１については、監査役による取締役の行為の差止請求（会社法３８５条）の要件については、法令違反行為は認定されうるものの、本件では、会社への著しい損害発生の要件は満たさないものと考えられ、請求は認容されないであろう。

なお、実務では、直ちに臨時株主総会を招集して、Ｂを取締役から解任し、退任慰労金の不支給決議を行うこととなろう。

Ⅱ

平成２６年の会社法改正で新たに導入された仮装出資の場合の履行責任に関する規律（会社法２１３条の２及び同２１３条の３、同２０９条２項・３項）の理解を試す設問である。

まず、本件新株発行に関するＹの払込み（「本件振込」）が仮装の出資に該当するかにつき検討する。仮装の出資に関しては、一般に、「預合い」と「見せ金」の二類型があるところ、本件では、後者である「見せ金」に当たるかが問題となる。見せ金については、当初から会社資金を確

保する意図がなく、一時的な借入金をもって単に払込の外形を整え、払込後に直ちにその払込金を払い戻してこれを借入先に返済する場合をいうものと解され、具体的には、①借入金の返済までの期間の長短、②会社資金として運用された事実の有無、③借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無により該当性が判断される（会社設立時の事案であるが、最判昭和３８年１２月６日民集１７巻１２号１６３３頁〔百選７〕を参照）。本問事案では、①Y は、９月２５日に１０００万円を銀行から借入、１０月１日に会社口座に同額を振込、１０月１０日に同額を引き出し、１０月１５日に同額を銀行に返済と、返済までの期間は短く、②そのため、会社資金として運用された事実は認められず、③発行済株式総数２０００株に対して、１０００株の新株を欠損てん補を目的として発行しており、会社の資金関係への影響も甚大であることから、見せ金として仮装の出資に該当すると解される。

そうすると、会社法２１３条の２第１項の規律の適用対象となり、X社は、仮装出資者であるY に対して、１０００万円の支払いを求めることができ、Y はその支払義務を負う。Y の責任は無過失責任である。なお、Y は、甲社の代表取締役として仮装出資を行っており、同法２１３条の３第１項の責任も負うが、両責任が重畳する訳ではない。

次に、本問後段につき検討する。会社法２０９条３項は、仮装の払込みによる株式を善意無重過失で譲り受けた者は、株主としての権利を行使することができるものとする。本問事例では、Z は、一連の仮装主出資（見せ金）の経緯につき善意で株式を譲り受けているため（１１月１日）、１２月のX社株主総会で議決権を行使することができる。なお、無償譲渡であることや、Z が Y の配偶者であることから、Z の善意・無重過失を疑うむきもあろうが、少なくとも善意は認定されており、重過失を認定するべき事実も問題文からは読み取れない。

以上

刑 法

2026 年度中期入試の刑法は、以下のような問題でした。以下、問題Ⅰ・Ⅱの順で解説と講評をします。

Ⅰ　次の【事例】を読み〔設問〕に答えよ（特別法違反の点は除く）。

【事例】
(1)　甲は、２名と共謀の上３月６日午前３時４０分ころ、普通乗用自動車後部のトランク内にＶを押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし、同車を発進走行させた後、呼び出した知人らと合流するため、市内の路上で停車した。なお、同車のテールランプはついていたが、ハザードランプはついていなかった。その停車した地点は、車道の幅員が約７．５ｍの片側１車線のほぼ直線の見通しのよい道路上であった。
(2)　上記車両が停車して数分後の同日午前３時５０分ころ、後方から普通乗用自動車が走行してきたが、その運転者は前方不注意のために、停車中の上記車両に至近距離に至るまで気付かず、同車のほぼ真後ろから時速約 60km でその後部に追突した。これによって同車後部のトランクは、その中央部がへこみ、トランク内に押し込まれていた被害者は、第２・第３頸髄挫傷の傷害を負って、間もなく同傷害により死亡した。

〔設問〕　【事例】における甲の罪責について、論じなさい。なお、論述に際しては、以下の①及び②の双方に言及し、自らの見解（①及び②で記載した立場に限られない）を根拠とともに示すこと。

①　甲に監禁致死罪が成立するとの立場からは、どのような説明が考えられるか。
②　甲には監禁罪が成立するにとどまるとの立場からは、どのような説明が考えられるか。

1　論　点

本問は、最決平成 18 年 3 月 27 日刑集 60 巻 3 号 382 頁の事案（以下、最決 18 年といいます。）を元に、因果関係を判断する規範とその具体的事案に対するあてはめをみようとするものです。因果関係を判断する枠組みは複数考えられるところ、各結論を導く具体的な違いをどのように解答するかという受験者の学習の深さを試そうとしています。

本事例の特徴は、被害者の直接の死因が、第三者によって形成された第 2 第 3 頚髄挫傷によるものであるということにあります。最決 18 年はこの点について「以上の事実関係の下においては、被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる」として、何らの規範を提示することなく因果関係を肯定しました。因果関係は構成要件要素の一部ですから、その判断が恣意的なものとな

らないためにも、因果関係の判断構造を理解し事案に応じて適切に用いることが必要です。

また、近時の司法試験ではある論点に対する異なる結論を説明させたうえで、自説を述べさせるものが出題されています。そのような問題への対応を見るために、因果関係を肯定する立場と否定する立場を論じたうえで、その当否を論じることも含めました。

2　問題の解説

本問では①②を小問として理解してはいけません。甲の罪責を論じるのですから、構成要件該当性、違法性阻却事由の不存在、責任阻却事由の不存在を確認して、最終的な甲の罪責を確定させることが必要です。

本問では、まず罪名として監禁致死罪（221 条）の成立が問題となることを指摘し、監禁罪の成立を確認します。そして、問題となるのは、V が監禁行為に「よって」死亡したといえるかという論点であることを指摘します。その際、本問ではＶの死亡の直接の原因は後続車の追突にある、という事実を指摘することが重要です。この作業によって、本問の論点が被害者の死因が第三者の介在行為にある場合の因果関係の判断方法であることが明確化するからです。

この点で、因果関係が問題となる、とだけ指摘するものや、論点を指摘することなくいきなり検討に入る答案が見られましたが、これでは、本問が受験者に何を問おうとしているかを理解している答案にはなりません。採点者に受験者が本問の出題意図に沿って答えているということをアピールするためにも、事実に着目して論点を作ることが必要です。

では因果関係をどのような枠組みで判断するべきでしょうか。因果関係の判断方法として、条件説、相当因果関係説、客観的帰属論などがあります。また近時では、いわゆる危険実現説が主張されていますが、危険実現説にはさまざまなバリエーションがありますので、危険実現説を取るとしたうえでさらにその判断構造を説明しておく必要があります。

①を説明する方法としては、相当因果関係説を取りつつ（問題となっているのは行為後の介在事情ですから、判断基底に関する学説の対立はあまり重要ではありません）、介在事情である追突事故が予見できるとして、判断基底に取り込み、Ｖをトランクに監禁しながら停車する行為から、追突行為によってＶが死亡する結果が発生することは相当であるとして因果関係を肯定する方法が考えられます。また、シンプルに監禁行為がなければ、追突事故もなく、Ｖが死亡することはなかったとして、条件説によって因果関係を肯定することもできます。

異なる説明として、危険実現説の中でも、①行為の持つ危険性、②介在行為の異常性、③介在行為の寄与度という 3 つの要素を考慮して監禁行為の持つ危険がＶの死亡という結果に実現したということも可能かもしれません。

次に②を説明する方法としては、相当因果関係説に立ったうえで、介在事情である追突事故を予見することはできないとする説明が考えられます。ただし、気を付けておいてほしいのは、相当因果関係における因果関係の判断は介在事情の予見すなわち判断基底の問題に尽きるものではないということです。相当因果関係説は判断基底に含まれる事情を材料として、当該行為から当該結果が出ることが我々の経験上相当といえるか、という因果経過の通常性を問題とする考え方です。したがって、介在事情が予見できないとしたとしても、さらに社会の経験則を考慮して行為と結果との間の相当性を検討しそれを否定することで、初めて②を説明することができます（い

わゆる狭義の相当性。そのような狭義の相当性を認めて因果関係を肯定した判例として最決平成 4 年 12 月 17 日刑集 46 巻 9 号 683 頁や最決平成 16 年 10 月 19 日刑集 58 巻 7 号 645 頁があります。また一般的な意味で介在事情が予見できなかったとしても、当該状況における具体的事実関係から、当該行為が介在行為を誘発して結果が発生した場合には、その因果経過が著しく不自然、不相当であったとはいえず、因果関係を肯定した最決平成 15 年 7 月 16 日刑集 57 巻 7 号 950 頁があります）。

本問では、夜間とはいえテールランプをつけた状態で道路に停車している監禁行為が、後行車が時速 60 キロメートルのまま停止車両に直前まで気づかずに追突してくるという事態を誘発したとはいえませんから、狭義の相当性も否定され、因果関係が否定されることとなるでしょう。

また上述と同様、危険実現説を取りながら、行為の持つ危険性が実現したとはいえず因果関係は否定されるということも可能です。

本問では、①②を説明したうえで自らの見解を根拠とともに示すことが要求されています。ここでは自説の根拠を述べたうえで、他説を批判し、自説の妥当性を説得的に論じることが求められています。

3　答案の講評

予想通りの結果でしたが、ほとんどの受験生が危険実現説を使って論述を進めていました。もっとも、①で因果関係を肯定し、②で因果関係を否定するという説明を説得的に論じられていた答案はほとんど見られませんでした。判例が本問と同じ事実関係で因果関係を肯定していることから、自説として①を取ることは決めているものの、②の説明を思いつかず、したがって自説を述べることもできず、監禁致死を認めるとした答案は低い評価にとどまっています。

また、危険実現説を取りながら、行為の危険性と介在行為の寄与度のみを問題にして因果関係を否定したうえで、介在行為の異常性を考慮に入れれば、因果関係を肯定できるとする答案が見られました。危険実現説においてどのような事情を考慮するかについての対立のように思えますが、なぜそのように危険実現説の中で考慮要素を変えることができるかについて説明できている答案はありませんでした。

危険実現説を取り、行為の危険性、介在行為の異常性、介在行為の寄与度という基準を用いて事実評価を変えて①、②の結論を説明する答案も複数見られました。しかし、基本的な事実関係が動かないにもかかわらず、同じ規範から異なる結論が得られるのであればその規範は因果関係の有無を判断するうえで有用ではないということになるのかもしれません。そこでは、追突行為一般の予見可能性と、衝突直前まで停止車両に気づかずに時速 60 キロメートルで追突するという具体的な介在事情の予見可能性のどちらを重視するのか、言い換えれば介在事情をどの程度具体化して予見の対象とするのかという判断が、結論を分けることを理解してください。

今の司法試験では、1 つの論点について異なる見解からアプローチし、それぞれの見解の利点や難点を論じさせる問題が出ます。単に規範や論証パターンを暗記するだけではこのような問題には太刀打ちできません。自分が持っている規範が、いったいどのような事案でどのような結論を導くために用いられていることを理解し、それと異なる結論を導く理論構成を知り、それぞれの利点と難点を理解するという学習が求められます。

Ⅱ　次の【事例】を読み、〔設問１〕および〔設問 2〕に解答せよ（特別法違反の点は除く）。

【事例】
(1)　甲は、自己の経営する会社の運転資金としてＡから金 100 万円を借り受け、その担保として自己所有の家屋（課税評価額 200 万円）一棟に抵当権を設定し、その抵当権登記に必要な白紙委任状、印鑑証明、権利証を一括してＡに交付した。
(2)　その後、甲は、さらに、自己の経営する会社の発行した手形の決済のための資金が必要となったため、Ｂから金 100 万円を借り受け、その担保として上記自己所有の家屋一棟に抵当権を設定し、その抵当権登記に必要な白紙委任状、印鑑証明、権利証を一括してＢに交付した。
(3)　上記家屋に設定された抵当権については、Ａよりも先にＢが登記をしたため、結果的にＡの抵当権は二番抵当権として登記されることとなった。

〔設問１〕　上記【事例】において以下の事情があった場合の甲の罪責について論じなさい。
(4)　Ａが登記をしなかったのは、甲がＡに来月払うからといって一ケ月毎に手形の書き替えをしたので登記をすることができず、さらに、甲は「来月こそ払うから登記をしないでほしい。君に弁済する前に他に担保に供して金を借りることはしない」と述べたからだという事情があった。

〔設問 2〕　上記【事例】において以下の事情があった場合の甲の罪責について論じなさい。
(5)　上記(4)と異なり、Ａが登記をしなかったのは、Ａが甲からの登記を済ませてほしいという督促にもかかわらず、多忙等の理由で登記手続きを怠っていたためであった。その間、甲は、自己の経営する会社の発行した手形の決済期日が迫り、不渡りを出す虞のある状態に陥っていた。

１　出題の趣旨

本問は、最判昭和 31･12･7 刑集 10 巻 12 号 1592 頁（『刑法判例百選Ⅱ各論　第 8 版』№70）の事案を題材として、背任罪（刑法 247 条）にいう「他人のためにその事務を処理する者」の意味を問うものです。

上記最判昭和 31･12･7 は、〔設問１〕に類似した事案について、「抵当権設定者はその登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負うものといわなければならない。」と述べて、背任罪の成立を認めた原判決を是認しました。しかし、これに対しては、「抵当権者に協力する任務」は抵当権設定者自身の任務であって、その任務が「主として他人である抵当権者のために負うもの」であるとしても、「他人のために『その』事務」つまり「他人の事務」には当たらないはずだとする有力な批判が加えられたのです。また、「主として他人のために負う事務」が「他人の事務」に当たるのなら、債務履行は主として債権者のための事務であるから、債務不履行一般もまた背任罪になりかねないとう問題もあったのです。

もっとも、このような判示にもかかわらず、上記最判昭和 31･12･7 の扱った事案は、〔設問 1〕の(4)にあるような、抵当権設定者が抵当権者による登記を妨げ、かつ、「他に担保に供して金を借りることはしない」と述べたというものでした。そこで、それとは反対に、〔設問 2〕の(5)にあるように、抵当権者が抵当権設定登記を懈怠しており、他方、抵当権設定者は、抵当物件の担保余力を利用した資金調達を迫られる情況にあったという場合にはどのように考えるべきかが問われます。もちろん、この場合には背任罪の成立を否定すべきですが、仮に〔設問 1〕で背任罪を認める場合、それといかにして矛盾のない説明ができるかが問われるのです。これが、本問の出題の趣旨です。

2　問題の解説

（1）　〔設問 1〕について

上記最判昭和 31･12･7（以下、「本判決」）と記す。）は、前述のように、〔設問 1〕類似の事案について、「抵当権設定者はその登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負うものといわなければならない。」と述べ、かつ、「一番抵当権を、後順位の二番抵当権たらしめたこと」は背任罪にいう「財産上の損害」に当たるとしました。

そこで、この判示に従い、本問の甲も、抵当権設定登記に関し、抵当権者である A に協力する任務を有しており、かつ、これは主として他人である抵当権者 A のために負うものであるから、甲は「他人のためにその事務を処理する者」に当たり、かつ、B に先に抵当権設定登記をさせたことで A の一番抵当権を後順位の二番抵当権たらしめたことにより A に「財産上の損害」を加えたものであって、それは「任務に背く行為」に当たり、さらに、それは「B から金 100 万円を借り受け、その担保として」行ったものであるから「自己……の利益を図」る目的も認められるとして、背任罪の成立を認めることはできます。

ただ、この説明では、〔設問 2〕においても背任罪が成立してしまうという問題を回避できなくなります。

そこで、一般には抵当権設定者に未登記抵当権の保全事務は委ねられていませんが、〔設問 1〕のような場合には、抵当権者は、抵当権を登記するという自己の抵当権保全事務を行わないで、その代わりに、当該未登記抵当権の保全事務を抵当権設定者に委ねたのであり、それゆえに抵当権設定者は抵当権者である他人の事務を処理する者に当たるとする処理が提案されています（松宮孝明「判解」『刑法判例百選Ⅱ各論　第 6 版』139 頁）。このように解すれば、〔設問 1〕において甲の事務処理者性を認めて背任罪を成立させつつ、次の〔設問 2〕では、同罪の成立を否定することができます。

（2）　〔設問 2〕について

前述のように、最判昭和 31･12･7 の判示にまともに従うと、〔設問 2〕でも甲に背任罪の成立を認めるという結論を回避できません。しかし、甲からの登記を済ませてほしいという督促にもかかわらず A が登記を怠っており、かつ、甲には不渡りを回避するために本件土地の担保余力を利用して資金調達をせざるを得ない事情があったにもかかわらず同罪の成立を認めることは、結

論の妥当性を欠くものとして回避すべきです。

そこで、上記と反対に、抵当権者が、それも督促されているにもかかわらず一番抵当権の登記を懈怠している場合には、抵当権設定者には何らの抵当権保全事務も委ねられていないとして、甲の事務処理者性を否定することが推奨されます。これにより、〔設問 2〕では、甲に対する背任罪の成立を否定することができます。

なお、事務処理者性を否定した場合には、これだけで背任罪の成立を否定できますので、同罪の他の要件を検討する必要はありません。ましてや、背任罪の本質を巡る「背信説」と「権限濫用説」の争いを大展開する必要はありません。

3　答案の講評

（1）　事務処理者性の検討

本問を選択した答案は、さほど多くはありませんでした。しかし、残念なことに、そのほとんどは、甲の事務処理者性の有無が中心論点であることに気づいておらず、その事務処理者性を認めた上で、〔設問 1〕において背任罪の成立を認め、その結果〔設問 2〕において慌ててその成立を否定しようとするものが目立ちました。

しかし、甲の事務処理者性を肯定しつつ他の要件で背任罪を否定しようとしても、B の抵当権を設定する行為は「B から金 100 万円を借り受け、その担保として」行ったもので「自己……の利益を図」る目的であることや、A の一番抵当権を後順位の二番抵当権たらしめたことにより A に「財産上の損害」を加えたものであることは否定できず、かつ、（A が登記をしないのであれば甲は B の抵当権を登記させなければよいのですから）それは抵当権者である A に協力する任務に背く行為であって、同罪の成立を否定することは難しくなります。中には、手形の不渡りを回避するための緊急避難だとする答案もありましたが、それでは、不渡りを出す虞が間近に迫っていないときには A の懈怠にもかかわらず同罪の成立を認めることになりかねません。したがって、事務処理者性を肯定しつつ他の要件で背任罪を否定することは無理だと思われます。

（2）　他の財産犯

一部には、〔設問 1〕において詐欺罪などの他の財産犯の成立を認める答案もありました。しかし、甲が手形の決済資金の必要に迫られたのは A に抵当権を設定した後のことであって、この時点では、まだ、A を欺罔する行為は認められません。したがって、A を被害者とする詐欺罪を認めるのは失当です。

他方で、未登記ではあるけれども A の一番抵当権が設定されているのに、この事情を秘して本件家屋を B に対する担保とした行為を詐欺罪とすることも、この時点で B の抵当権を二番抵当権とする意図は認められませんので、無理だと思われます。

ましてや、本件家屋は甲の所有物であり、それが不法領得されたわけではありませんので、横領罪や窃盗罪などの財産犯は本問では検討の余地すらありません。このような余計な財産犯の成立を認めることは論外ですので、これを認めた受験者は、財産犯の勉強をし直してください。

4　最後に

財産犯では、民事の権利義務関係を正確に理解し、かつ結論の妥当性を担保できる利益衡量をして、設定が変わった場合でも矛盾なく妥当な結論が保障される理論構成を心がける必要があります。このような態度で学習を深められることを期待します。

以上

小 論 文

設問Ⅰは、不平等に反対する理由について、筆者の見解を問うものである。課題文において著者は、不平等に反対する理由について 4 点指摘して次のように論じる。

第 1 に、不平等は剝奪であり、貧窮ゆえの苦しみや生活困難をもたらすということである。これは直感的にわかりやすいが、現代社会は生活保護制度をはじめとする福祉制度を備えており、少なくとも公式上は貧困への配慮がなされている社会では、必ずしも平等である必要はないことになる。したがって、貧困の除去は不平等とも両立することから、剝奪はもちろん不平等に反対する理由にはなるが、中心にあるとまではいえない。

第 2 に、スティグマ化、すなわち、社会的地位の不平等によって少数派に対して差別や偏見を生じさせるということである。そして、スティグマ化を悪化させることについて次のような説明が可能であるとする。まず、貧困それ自体から生じる。貧困な者がアウトサイダー化したり、規範を逸脱する行動様式をしばしば身につけるということである。次に、貧困対策から生じるものがあり、例えば生活保護を受けることは社会的な無能力者だとのレッテルを貼られやすいことから、受給せず劣悪な環境で働き続けることになる。更に、格差から生じるものがある。富者は自らを過大評価し、貧者を過小評価しがちであり、ステレオタイプの嘲りや不信、恐れや怒りを増幅させる。

第 3 に、不平等は不公平なゲームになるということで、「機会の平等」に関わるものである。すなわち、平等な者としての扱いを可能にする前提を歪めることになるということである。いわば人生というゲームのなかで、生まれ育った環境次第で難易度が大きく変動するのである。受験を例にして考えてみても、収入等の環境格差によって大学進学の難易度が変わり、その後の人生も大きく変動する。そのため形式的な機会の平等だけでは人生というゲームの平等は実現できず十分とはいえない。

第 4 は、支配関係が社会的経済的格差によって固定されるということである。経済的な富者に権力が集中し社会的影響力の偏在があることである。すなわち、社会的経済的格差によって権力が一部の特権層に集中し、その他の人々に対し恒常的な影響を及ぼす状態になり固定することである。このような支配関係―非対照的な関係の固定化―がある社会は平等とはいえない。

このように、筆者は不平等について反対する理由を 4 点をあげ説明した上で、第 1（剝奪）、第 2（差別）の理由は見えやすく、放置さるべきではないという判断についてはコンセンサスが成立していると言ってよいだろうが、第 3（不公正さ）、第 4（支配）は見えにくく判断が分かれると論じている。

ほとんどの答案は不平等に反対する理由について 4 点のキーワードを挙げていた。しかし、それぞれの内容のうち、第 3、第 4 に関する論述が薄いものや、挙げたキーワードと内容に齟齬が見られるものもあった。答案のかなには、第 3、第 4 の理由について分析を加えて独自に優劣をつけてまとめていたものや、第 1 から第 4 の理由について分析して自らの見解を述べたものもあった。単に 4 つの理由について表面的に述べるだけでなく、ささらにその内容を的確に述べた答案や第 1、第 2 の理由と第 3、第 4 の理由の相違についても論じたり、相違に基づいて筆者の見

解を論じた答案の評価は高い。一方、キーワードと内容に齟齬があったり一部の理由しか述べていない答案の評価は低い。

設問Ⅱは、筆者が主張する「強い平等主義」の立場から「弱い平等主義」に対する批判を説明した上で、政治における寡頭制の問題点を平等主義の観点に照らして解答者の見解を問うものである。

まず、筆者は、「弱い平等主義」と「強い平等主義」について説明している。前者は、貧困や差別といった「みえやすい不平等」に対しては是正の必要性を認めるが、機会の不均等、不公正さや支配構造といった「みえにくい不平等」には対処する必要を認めない立場である。後者は、「見えやすい不平等」も「見えにくい不平等」も対処する必要があると考える場である。その上で「強い平等主義」の立場から「弱い平等主義」を批判する。

まず、「弱い平等主義」の立場からは、貧困を一応解決した社会に、道徳の荒廃を伴って再び貧しさが回帰してくるという窮民問題について対処できない。歴史的には、社会の富の増加に伴い発生した貧困対策としての社会福祉の先駆けのような営みが行われた。しかし、一方的に施すだけでは貧者の誇りが失われることになったり、他国が収奪の対象となったり等様々な問題が生じる。その中で、最低限の生活保障の条件が崩れると窮民が現れる。窮民は貧民とは区別され、窮民は、市民社会での自己実現を目指すチャンスを再び閉ざされ、誇りや自尊心を喪失させることになる。そうすると、貧困は社会に起因する不正義だと考えられるようになり、窮民は毀損された心情を持つが故に独善的な行動に及び社会を荒廃させることになる。この問題が示しているのは、「みえやすい不平等」を本当に解決するためには、より根深い「みえにくい不平等」への対処が必要ということである。

次に「弱い平等主義」は、「少数の人が・公共の利益にかなっていない」政治、具体的には少数の富裕層が政治的に支配し権力を握るという、寡頭制の問題に対応できない。寡頭制的な人間は、際限なく拡張する欲求に絶えず支配され、自らに都合のいいように政治プロセスを歪める。その社会は、金銭への欲望に長けた人間が権勢を誇るような社会であり、富者と貧者の格差が更に広がる。そのため不満を惹起し、ついには圧倒的多数の貧者が少数の富者を打ち倒すという多数の貧者による政治になってしまう。そこでは「まやかしの言論」が登場し、誰か 1 人を先頭に押し戴く僭主独裁制へとゆきついてしまう。僭主は自分の敵を孤立させ、社会を分断し次第に好き勝手にふるまうようになる。このことは今日のポピュリズム政治をも連想させる。「見えにくい不平等」を放置すると、やがてそれは僭主政という「見えやすい不平等」にゆきつく。僭主の出現を阻止するためには「強い平等主義」の立場から、寡頭制問題に対処することが必要である。

さらに、「弱い平等主義」の立場では、社会全体の健康格差の問題に対処できない。不平等が大きい社会では、富裕層をも含めた社会全体の健康状態を悪化させる。富裕層であっても日々のプレッシャーの中で心身に失調をきたす人は少なくない。不平等が大きい社会では、ロールズが論じるような①自分にとって重要な生きがいがあり、②それを実際に追求できるような場合に可能となる「自尊」という道徳感情が保障されない。現実に目を向けると、「絶望死」や「セルフ・ネグレクト」などの現象が注目され、これは経済的困窮だけでなく、社会的孤立や自己価値の喪失によって引き起こされる。このような健康格差の問題は「見えにくい不平等」に関わるものであるから、「弱い平等主義」では対処できない。正義にかなった社会は「自尊の社会的基盤」を保

障しなければならず、何らかの価値観や生き方が不当に抑圧されない社会になるためには、このような「見えにくい不平等」に対処するものでなければならない。

本設問は「弱い平等主義」を「強い平等主義」の立場からの批判について論じなければならないから、「弱い平等主義」と「強い平等主義」とは何かについて、まずその定義を論じる必要がある。多くの答案はそれについて論じていたが、論じていない答案も一定あった。同様に「政治における寡頭制」とは何かについて説明していない答案もあった。また、「強い平等主義」の立場からは上記のとおり、筆者は 3 点を問題にしているが、救貧化については詳しく論じ他の問題についてはほとんど論じていない答案もあった。特に、第 3 の健康格差について、論じている答案が少なかった。設問が、「政治における寡頭制」の問題点ということから、第 3 の健康格差について見逃してしまったのかもしれない。しかし、筆者は「弱い平等主義」の問題として健康格差問題を重視しているから、この点を的確に論じなければならない。また、寡頭制の問題について平等主義の観点から解答者の見解を問うているのに、それ以外の問題について論じたり、平等主義と結びつけて論じていない答案も散見された。

「弱い平等主義」の問題について上記の 3 点について的確に論じた上で、寡頭制の問題点を、「弱い平等主義」の観点と「強い平等主義」の観点に関連付けて、自己の見解を述べている答案は評価が高い。一方、上述したとおり「弱い平等主義」の問題点として健康格差問題について論じていなかったり、各問題点の指摘が希薄で寡頭制の問題を独自平等主義と結びつけて論じていない答案の評価は低い。また、私見を述べていない答案もされたが、そのような答案の評価も低い。

以上